

0018688-64.2018.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... e, alternativamente, a desclassificação de roubo majorado para roubo simples, a fixação da pena no mínimo, o reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial semiaberto e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018688-64.2018.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018688-64.2018.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 3137/2017 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diogo Antonio da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

FÁBIO AUGUSTO THOMAZ, MICHEL LOPES DE OLIVEIRA e DIOGO ANTÔNIO DA SILVA foram dados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 01 de setembro de 2017, por volta de 6:20 h, na rua Coronel Alves Seabra, n. 15-67, bairro Vila Seabra, nesta cidade, em concurso e com unidade de propósitos, devidamente associados para o fim específico de cometer crimes de roubo, subtraíram para eles, mediante violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia em espécie de R\$ 500,00, pertencentes a Francisco Peral e sua esposa Maria Neide.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 05 de janeiro de 2018 (fls. 192/194).

O réu Fábio foi citado (fls. 330) e apresentou a defesa preliminar de fls. 374/

O réu Michel apresentou a defesa preliminar de fls. 346/350.

O aditamento da denúncia foi recebido por despacho datado de 08 de abril de 2018 (fls. 366).

Em relação ao réu Diogo, o curso do processo e o prazo prescricional foram suspensos por despacho datado de 29 de novembro de 2018 (fls. 495/496). Citado pessoalmente em 12/09/2021 (fls. 552), o acusado Diogo apresentou a defesa preliminar de fls. 557/596, alegando que: 1)- a defesa não teve acesso ao processo referente à interceptação; 2)- houve apenas presunção de que a pessoa que conversou com Michel foi Diogo, alijercada em análise e cruzamento de dados das torres de telefonia próximas à casa da vítima, ignorando que Diogo residia no bairro quando do fato; 3)- não foram feitas apurações no celular de Diogo; 4)- ele não foi reconhecido pela vítima; 5)- a denúncia é inepta, pois não indicou o papel desempenhado por cada qual dos réus; 6)- não há justa causa para a ação penal; 7)- o réu deve ser absolvido, seja em função da inexistência de provas, seja em razão da irrelevância penal do fato; 8)- o roubo deve ser desclassificado para sua forma simples, pois o réu não usou arma, o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal foi revogado, não há prova de que Diogo obteve posse mansa e pacífica da coisa, Em audiência, foram ouvidas a vítima e testemunhas e o réu Diogo foi interrogado (fls. 725 e 738 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 744/749).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 755/794, reiterando os termos da resposta à acusação e acrescentando que: 1)- em juízo, não foram produzidas provas suficientes para a condenação; 2)- as vítimas afirmaram que os criminosos não foram rudes ou violentos, bem como que não foram agredidas e nem ameaçadas; 2)- Diogo disse que não sabia da arma até o momento do fato e que não teria ido ao local se tivesse arma de fogo; 3)- eventualmente, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, fixado o regime inicial semiaberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa; 4)- deve-se reconhecer o direito de apelar em liberdade. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação de roubo majorado para roubo simples, a fixação da pena no mínimo, o reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial semiaberto e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 18/19, pelo trecho do relatório de investigações contido a fls. 41/43, pelo laudo pericial de fls. 52/58 (um revólver calibre .38, apta à realização de disparos, e 4 cartuchos) e pelo auto de apreensão de fls. 64/65 (um telefone celular linha 14 99122-4101; e quatro telefones celulares das marcas Claro (2) e Tim (1) e um outro sem identificação).

A autoria deriva dos demais elementos de prova e deve ser atribuída aos réus.

Conforme relatório de investigações de fls. 41/47, foi interceptado o telefone do réu Michel, em procedimento da 2ª Vara Criminal da comarca. Foram percebidas conversas nas primeiras horas da manhã de 01/09/2017, compatíveis com a dinâmica do roubo aqui em análise (fls. 44).

Outrossim, através do sistema Vigia, foi possível verificar que as antenas das torres de telefonia captaram a presença dos celulares dos réus na direção da residência da vítima, ou seja, quadra 14 da Rua Alves Seabra (fls. 14).

Os diálogos revelaram também a identidade dos coautores: Diogo e Fábio, este último usuário da linha 14 99122-4101, cadastrada em nome de sua amásia.

Essa linha telefônica foi objeto de monitoramento no processo n. 28243-42 da 3ª Vara Criminal, tendo sido verificado que está cadastrada em nome de Eva Raquel de Souza, a amásia de Fábio (fls. 45).

Captou-se contato telefônico envolvendo Fábio (linha n. 14 99122-4101) e Michel (14 99666-8429), às 5:53:34 h do dia 01/09/2017, em que o primeiro disse "to indo aí". (fls. 45).

Na mesma data, Michel manteve contato com Diogo (linha n. 14 99809-0847) contato às 6:19:59 h e lhe perguntou onde estava. Diogo respondeu estar "aqui". Michel pediu que subisse a rua, "que o amigão subiu pra ir lá". Diogo falou para esperar. Michel: "Que espera rapaz. O velho foi lá comprar o negócio lá amigão". Diogo:

"pela rua debaixo?". Michel: "Burro. No mesmo lugar de ontem, eu tô aqui na rua virando". (fls. 45/46).

Às 6:23:52 h, Michel e Diogo voltaram a se falar. Ouviram-se latidos de cachorros ao fundo. Michel disse: "O filho dele tá aí em cima, entendeu, na área. Na área". Diogo falou que ele gritou. Michel insistiu: "Ele apareceu aí em cima". Diogo: "Ele gritou, ele gritou, escutou?". Michel: "Eu escutei. Ele apareceu aí em cima entendeu?". Diogo: "eu acho que o filho dele escutou". Ao fundo, ouviu-se a voz da vítima Francisco (fls. 46).

A vítima Francisco esteve na delegacia de polícia e ouviu a gravação dos diálogos, tendo reconhecido sua voz e a de sua esposa, bem como os latidos de seu cachorro (fls. 46).

O filho de Francisco, de nome Leonardo, também foi à delegacia e reconheceu as vozes dos pais e o latido do cachorro (fls. 47).

Em juízo, a vítima Francisco afirmou ter ido à padaria, como o faz todas as manhãs, depois de acordar por volta de 6:00 h. Comprou pão e estava voltando. Notou que havia um carro parado para cima da esquina de sua casa. Ao bater o portão de sua residência, um indivíduo forte bateu no portão. Tentou segurar o portão e não conseguiu. O criminoso entrou em sua casa e o rendeu, assim como sua esposa. Ele lhe apontou arma na cabeça. O portão abriu-se novamente. Achou que fosse seu filho e gritou, "Leonardo, sai, não entra aqui". Um segundo indivíduo, mascarado, entrou no imóvel e lhe disse que seu filho estava rendido. Só tinha falado o nome de Leonardo, mas não que era seu filho. O indivíduo, pois, conhecia sua família. O criminoso que apontou-lhe revólver na cabeça queria cofre. Explicou-lhe que não tinha cofre. Diogo, que estava mascarado, adentrou para ver se achava algo mais. Acredita que ele tinha um celular embaixo da máscara pois, ao voltar após procura por bens no interior do imóvel, afirmou "sujou" pois havia barulho na rua. Entregou ao criminoso que lhe apontava revólver cerca de quinhentos reais, que estavam em sua carteira. Os dois saíram correndo. Diogo é seu vizinho e o conhece. No momento do crime, não o reconheceu porque ele estava mascarado. O primeiro a entrar em sua casa tinha 1,80 m, era forte e tinha pele escura. Ele somente puxou a camiseta até o nariz. A camiseta escorregou e, por isso, conseguiu reconhecê-lo na primeira audiência. Os indivíduos fugiram na posse dos quinhentos reais subtraídos. Acha que foi Diogo quem armou o esquema para entrar em sua casa, pois o conhece há muitos anos. Ele reside a um quarteirão de distância e não saía de sua loja de materiais para construção. Embora não o tenha reconhecido no momento do fato, o aspecto físico do criminoso mascarado era compatível com o de Diogo. A estatura era a mesma. Notou semelhança também em relação a voz. Depois, identificou que se tratava da voz de seu vizinho. Foi o segundo indivíduo a entrar na casa, dizendo que seu filho estava dominado, apesar de ela, vítima, ter se referido apenas a "Leonardo". Posteriormente, ao ir na delegacia, reconheceu a voz de Diogo. Seu filho mora na esquina. Como ouviu barulho do portão, achou que era Leonardo quem estava entrando. Ao gritar o nome de Leonardo, o criminoso mascarado estava adentrando em seu imóvel. Na delegacia, ouviu os áudios atinentes a uma interceptação telefônica, tendo então reconhecido suas vozes e o latido de seu cachorro. Ouviu o som de sua cachorra latindo e o indivíduo dizendo a todo momento que queria cofre. Esse indivíduo era o que estava com o revólver em sua cabeça. Sua voz apareceu em volume bem baixo, pois estava detido no chão. Sua esposa também estava no chão.

Reconheceu, da mesma forma, a voz dela no áudio. Tem 100% de certeza de que um dos rapazes era Diogo, em razão de ele se referir ao seu filho e pela maneira como falava, bem como pela apreensão do celular que lhe pertencia. No momento do crime, não sabia tratar-se de Diogo. Inicialmente, não falou que o criminoso era Diogo para a polícia. No decorrer da investigação, foram-se fechando todas as pontas, e então teve certeza de que Diogo foi um dos autores do crime. Tem 1,68 m de altura. O indivíduo era mais baixo do que ele, Francisco. Acredita que ele estava com o celular embaixo da máscara, conversando com o motorista. Diogo não estava armado e não colocou o revólver em sua cabeça. Ele somente não levou outras coisas e nem judiou mais dele e de sua esposa porque houve barulho na rua. Diogo, então, apavorou-se e foi para o carro. Diogo também não o agrediu. Apenas o outro colocou o revólver em sua cabeça. Levaram-lhe apenas quinhentos reais porque ouviram o

barulho na rua. Do contrário, teriam-lhe subtraído mais. Seu cachorro é da raça Fox Paulistinha. Diogo sempre se envolvia em pequenas roubos. Via-o sempre na rua e não sabe se ele trabalhava ou não.

A testemunha Leonardo relatou ser filho de Francisco e de Maria Neide. Trabalha junto com seu pai e acordam no mesmo horário. Suas casas não têm ligação. Sua residência é de esquina e tem uma sacada para a rua, pela qual vê a via pública de frente e a da lateral, denominada Santa Generosa. Ao ouvir o barulho, pensou que viesse da rua Santa Generosa, e não daquela onde se situa a residência de seus pais. Ao colocar o rosto para olhar, viu um automóvel Celta, cor preta, estacionado. Percebeu que o portão da habitação de seus pais bateu. Foi até o outro lado e se debruçou na sacada, para olhar melhor. Não ouviu barulho naquele momento. Depois, ouviu barulho novamente. Após algum tempo, notou que dois bandidos saíram da casa de seus pais. Não foi até o imóvel dos genitores. Os dois criminosos correram por baixo da sacada e depois pela rua lateral. O carro já não estava mais ali. Viu os dois indivíduos entrando no veículo. Um deles, o maior, era moreno e tinha cerca de 1,80 m de altura. Quando o investigador esteve em sua casa e lhe mostrou fotos, disse ao mesmo que o criminoso era alto. Já havia visto o rosto desse primeiro indivíduo de cima da sacada. Ele, ao sair, fez menção de colocar o capuz e retirar. O outro era magro e tinha cerca de 1,70 m de altura. Ele estava de capuz e não conseguiu observar seu rosto. Chegou a correr um trecho atrás dos dois quando eles saíram da residência de seus pais e, então, conseguiu vê-los melhor. O indivíduo de máscara lembrou-lhe Diogo. Conhece-o desde pequeno. Não quer acusar ninguém, mas também não quer sofrer. Diogo morava nas proximidades, junto com familiares. Na data do fato, não ouviu a voz dele. Diogo foi o segundo a entrar na residência de seu genitor. Não chamou por seu pai. Tudo foi rápido. Ao ir de uma ponta para outra de sua sacada, distância de cinco metros, e ouvir o portão bater, notou que algo ocorria na casa de seu pai. Ao escutar um primeiro estrondo, tipo uma discussão, foi à sacada e olhou para a esquina. Ouviu, então, bater o portão da casa de seu pai. Olhou para baixo e nada viu. Mas ouviu seus pais gritando dentro da residência. Em seguida, os dois criminosos saíram do imóvel. Para sair de sua casa, tem que atravessá-la inteira para abrir o portão. Saiu da sacada. Viu-os correndo e entrando no veículo Celta, o qual estava em outro local, em via paralela com a rua Alves Seabra. Ouviu os áudios na delegacia. O barulho interno de seus pais e da cachorra, bem como a conversa em si, havia escutado tudo. Ao ouvir seus pais no áudio, ficou arrepiado e desesperado. Tem certeza que as vozes eram de seus pais e o latido, da cachorra deles. O rapaz do carro falou "sujou, o filho deles acordou". Foi então que entendeu que havia mais uma pessoa dentro do carro. Na audiência de instrução, reconheceu o réu como sendo Diogo. Tem 100% de certeza de que o segundo indivíduo era Diogo. A estatura do indivíduo lhe era semelhante. Ao correr atrás dos indivíduos, viu-os andando. O investigador lhe trouxe dez ou quinze fotos, de pessoas de diferentes características. No decorrer da investigação, chegou-se a Diogo. Sabia que ele não era pessoa de boa índole. A certeza sobre ser Diogo um dos autores do crime veio durante a investigação. A casa de seu pai se situa ao lado da sua, cerca de cinco ou seis metros de sua sacada. Foi a essa distância que viu os criminosos saindo. O de maior estatura, ao sair, deixou cair o capuz para trás, possibilitando que visse seu rosto. Diogo estava de máscara, mas foi possível ver suas sobrancelhas e testa, bem como a cor da pele e o olho puxadinho. Notou que ele estava com as duas mãos no bolso. Num dos bolsos, havia um volume e, no outro, algo dourado, que devia ser um celular. Seu terreno é torto. Da sacada, viu o carro. O quarteirão tem apenas 50 metros. O terceiro indivíduo virou o carro e aguardou os outros dois. Sua sacada é voltada apenas para uma rua, que é aquela onde mora seus pais e não aquela onde estava o veículo. Porém, quando se coloca a cabeça, consegue-se ver a rua inteira. Como sua casa se situa a cerca de 45 graus da via pública, consegue ver também a rua do lado. O segundo indivíduo, mascarado, devia ter aproximadamente 1,65 m ou 1,70 m de altura, e era bem mais baixo do que o outro. O motorista do veículo viu-o e virou o carro, passando a aguardar na rua de cima. Os dois criminosos passaram em frente de sua residência, entraram no veículo e fugiram. Ouviu o áudio e tem plena convicção de que eram as vozes de seus pais.

A testemunha Cledson Luiz do Nascimento, delegado de polícia, relatou que Michel era alvo de outra investigação, realizada com auxílio de interceptação, relacionada a furtos de veículos. Ele tinha antecedente de roubo a residência de 2014. No transcorrer da investigação, os investigadores flagraram a prática de um roubo a residência na região do Jardim Vitória. O carro da vítima e seus objetos foram achados em Ourinhos. Identificou-se Michel conversando com outros dois comparsas. O telefone celular estava cadastrado em nome dele. Michel chegou a fazer uma ligação para o telefone fixo da casa da amásia, inclusive tendo comentado sobre o crime. Michel foi flagrado na posse das joias roubadas no crime ocorrido em 15 de setembro e foi autuado em flagrante. A equipe notou que, no roubo do dia 01/09/2017, as mesmas circunstâncias se apresentaram, inclusive o uso de um veículo Celta. Notou-se que Michel ficou do lado de fora, mantendo contato com a mesma linha cadastrada em nome de Diogo. Pouco antes do roubo, Michel havia mandado mensagem de texto para celular cadastrado em nome da esposa do corréu Fábio. Na época, Diogo era evadido da Penitenciária de Marília e não foi localizado, razão pela qual foi indiciado indiretamente. Ele foi recentemente detido em Araçatuba. Na data do delito, Michel se comunicou com outra pessoa, dizendo situações relacionadas ao fato. Foi possível interpretar que Diogo estava na residência e Michel, do lado de fora. Em conversa relacionada ao roubo do dia 15, notou-se que Diogo fez uso do celular de Michel. Foi possível perceber que "Amigão" era Diogo e que ele usava o aparelho de Michel. No roubo à residência do Jardim Vitória, foi subtraída uma arma de fogo, de propriedade da família. O veículo também roubado na ocasião foi abandonado em Ourinhos. Michel foi preso em flagrante na posse da arma, do veículo e de parte de outros bens subtraídos. Não se recorda se, na ocasião, houve a apreensão do telefone celular de Michel. O ofendido do roubo do dia 01/09/2017 e seu filho ouviram o áudio oriundo da interceptação judicial. A diligência foi precedida de autorização judicial. Eles confirmaram que o áudio retratou o crime ocorrido naquela oportunidade.

A testemunha Cristina Regina Gomes de Faria Mostaço, investigadora de polícia, relatou que investigava roubos de veículos. Durante a interceptação, foram captados diálogos relacionados a dois crimes de roubos a residências. Num deles, a esposa de Diogo ligou para ele, pois ela estava preocupada por ter visto helicópteros na região. Soube-se que a era a esposa do réu porque a investigação já perdurava por alguns meses, com interceptação. Foram meses ouvindo os três acusados, o que facilitou a identificação. Cada investigador ficou responsável por um suspeito. Não fez o acompanhamento de Diogo. Ficou responsável por ouvir Michel. Ocorreram contatos entre Michel e Diogo, tanto durante a investigação como na data do crime. Michel era investigado por roubo e furto de veículos apenas. Contudo, acompanhou-o em tempo real quando dos dois roubos a residência. Já havia visto Michel com o carro modelo Celta, de cor preta, o qual, inclusive, restou apreendido em outra diligência. Não se recorda o nome da esposa ou companheira de Diogo. Mas tanto ele como os demais investigados entraram em contato com os familiares. Vários telefones foram interceptados, inclusive o de Diogo. Não tem mais acesso aos dados do inquérito referentes à interceptação. Não sabe se houve perícia para atestar ser de Diogo a voz captada nos diálogos interceptados.

A testemunha Cássio Rogério da Cunha, policial civil, informou ter trabalhado na investigação do crime. A interceptação ficou a cargo dos colegas Décio e Cristina. No início, uma equipe estava investigando Michel. O telefone dele foi interceptado. Michel foi preso em flagrante na posse de arma e objetos. A prisão ocorreu perto da avenida Castelo Branco. Não se lembra o nome da vítima. Diogo participou desse assalto, mas fugiu e não foi preso. O roubo em questão ocorreu, salvo engano, depois do crime tratado neste processo. Quando da prisão em flagrante de Michel, em seu poder foram apreendidos as armas dele e da vítima e um celular dele. Referido aparelho de telefone foi utilizado por Diogo, quando este ligou para a amásia a fim de afirmar que cometeu assalto e que fugiria por um tempo. Com autorização judicial, as vítimas da rua Alves Seabra foram convidadas a ouvir os áudios derivados da interceptação captados na data do fato. As vítimas reconheceram suas vozes e o latido de seu cachorro. Há imagens de monitoramento nas quais se viu o veículo Celta no entorno da residência do ofendido. Pela percepção da polícia, foi

Diogo quem idealizou o assalto. A vítima tinha uma loja de materiais de construção, razão pela qual os criminosos pensaram que ela poderia ter elevado valor em dinheiro em casa. No telefonema para a esposa, Diogo disse que cometeu um assalto e que, por isso, ficaria afastado por algum tempo. Não sabe dizer como se identificou que Diogo foi quem fez essa ligação. Michel era quem estava com o telefone interceptado. Por isso, quando Diogo fez a ligação para a amásia, a captação foi feita através da linha telefônica de Michel.

A testemunha Décio Hojas Lofrano, investigador de polícia, afirmou não se recordar exatamente qual função desempenhou na investigação. Não se recorda de um diálogo entre Diogo e a esposa, ocorrido dias depois do crime ora em apuração. Captou imagens do local do delito. Nelas, viu-se toda a preparação e dinâmica dos fatos. Viu o carro suspeito fazendo campana na casa da vítima. Ela saiu para ir à padaria pela manhã. O veículo de Michel acompanhou-a. Os réus estavam sendo interceptados. Salvo engano, o mesmo carro foi visto em data anterior no local, monitorando o ofendido. Diogo foi identificado como um dos criminosos que adentrou na residência da vítima. Não foi possível identificar quem dirigia o carro. Não se lembra bem se as imagens referiam-se também a data anterior ao delito. Não houve dúvida de que Diogo foi o segundo indivíduo a entrar na casa da vítima. Diogo morava perto do ofendido e sabia de sua rotina. Por isso, ele entrou com o rosto totalmente coberto, o que impossibilitou seu reconhecimento. As imagens não tinham qualidade suficiente para permitir a identificação do motorista do veículo.

A testemunha Paula Carolina Silva afirmou conhecer Diogo da época em que ele vendia bacias. O réu deslocava-se bastante pela cidade. Nada sabe sobre o crime. Não conhece o corréu Michel. Diogo sempre se mostrou ser excelente homem. Ele é trabalhador, tem dois serviços, tem bom convívio com as pessoas. Quando Diogo conheceu a esposa, ele mudou bastante. Diogo ama os filhos e vice versa. Ele nunca foi agressivo, dificilmente fala palavrões e se dedica a família.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime. Queria pedir perdão para Francisco em razão do que fez. Não tem como falar que não é ele, pois mudou de vida. Sua família está necessitando dele lá fora. Precisa falar a verdade pois, do contrário, não chegará a lugar nenhum em sua vida. Aceitou Jesus. Trabalha em restaurante e tem uma mercearia com sua esposa. Após o fato, teve dois filhos, um deles com três meses de idade. Está arrependido. Não deveria ter feito isso. Na data do crime, não agiram com violência. Não queria que os comparsas usassem armas. Agiu na companhia de duas pessoas. Uma delas estava armada. Não queria que fossem ao local com arma de fogo. Tinha um outro filho, nascido antes da data do crime. Conhecia a vítima, a qual morava no mesmo bairro de sua mãe. Quando ia na residência da genitora, via o ofendido. Ele tinha uma loja de material de construção no bairro. Quando da prática do delito, não portava arma de fogo. Não agrediram nenhuma vítima.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado Diogo nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa que sustentam o contrário.

Não há que se falar em inépcia da denúncia.

A inicial descreve que Diogo, em comparsaria com Fábio e Michel, subtraiu a quantia de quinhentos reais da vítima Francisco, mediante violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Aponta, em seguida, que, quando o ofendido retornava para casa depois de ter ido à padaria, foi abordado pelo corréu Fábio, que adentrou no imóvel e lhe apontou arma de fogo. Francisco entregou a quantia de R\$ 500,00. Após, Diogo ganhou o interior da habitação, novamente rendeu as vítimas e deu continuidade ao assalto. Enquanto esses dois criminosos ameaçavam as vítimas, Michel aguardava-os do lado de fora, em um veículo, dando segurança à atividade criminosa.

Como se nota, ao contrário do que sustenta a nobre defesa, a denúncia cuidou até mesmo de especificar as condutas de cada um dos acusados, as quais restaram comprovadas durante a instrução.

Enfim, pois, a inicial acusatória era apta a permitir o desenvolvimento da ação penal, tanto que o réu exerceu seu direito ao contraditório e à defesa de forma plena.

Quanto ao tema de fundo, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria restaram bem comprovados.

O réu confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A confissão judicial já seria elemento de prova bastante para condenação.

Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, está corroborada pelas declarações da vítima e de seu filho Leonardo, segundo os quais o segundo indivíduo, mascarado, tinha o mesmo porte físico de Diogo, pessoa que já conheciam por ser vizinho.

Observe-se que Leonardo afirmou, inclusive, que, apesar de o criminoso estar usando máscara, foi possível ver sua sobancelha, sua testa, seus olhos "puxadinhos" e a cor de sua pele.

Ademais, a vítima Francisco e seu filho Leonardo ouviram a gravação oriunda da interceptação telefônica, captada no momento da prática criminosa.

Ambos confirmaram que as vozes eram da primeira e de sua esposa, bem como que o latido era da cachorra do casal.

Não vinga o argumento de que não se têm elementos para afirmar que Diogo era um dos interlocutores dos diálogos.

Como afirmou o delegado Dr. Cledson Luiz do Nascimento em seu depoimento em juízo, a linha telefônica utilizada na ocasião do crime estava cadastrada no CPF de Diogo. A mesma informação consta do relatório de investigação a fls. 45: (14) 99809-0847 (linha cadastrada em nome do autor Diogo Antônio da Silva).

Outrossim, tanto o Dr. Cledson como o investigador de polícia Cássio narraram na fase judicial que, em ocasião posterior, Diogo, utilizando-se do telefone de Michel, fez uma ligação para o telefone fixo da casa de Caroline, sua esposa, informando que havia se envolvido num assalto e que ficaria afastado por algum tempo.

Embora não tenha havido perícia fonética, não se pode sustentar que não foi Diogo quem protagonizou o telefonema em questão.

Afinal, quem ligaria para a cônjuge dele, para confidenciar que cometeu um crime grave e que, por isso, iria se manter distante por algum tempo ?

É fora de dúvida, portanto, que Diogo foi um dos autores do crime.

As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo não podem ser afastadas.

A prova oral revelou que o crime foi cometido por ao menos três pessoas.

Com efeito, o ofendido Francisco afirmou que dois criminosos adentraram em sua residência para cometer o assalto, ao passo que a testemunha Leonardo, que muito viu do lado de fora, de sua sacada, relatou que havia um terceiro indivíduo, que permaneceu no volante de um veículo parado nas proximidades, no qual os dois primeiros adentraram e fugiram depois da prática do crime.

A prova também permite afirmar que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo.

A vítima Francisco foi clara ao dizer que um dos assaltantes (réu Fábio) apontou-lhe um revólver na cabeça.

Observe-se que houve a apreensão de um revólver calibre .38 na posse de Michel, comparsa do réu Diogo na prática criminosa ora analisada, quando o primeiro foi preso em flagrante por delito análogo ocorrido quinze dias depois.

Vale ressaltar que a arma de fogo apreendida foi submetida a perícia, que constatou tratar-se de artefato hábil a efetuar disparos.

Não vinga o argumento de que não foi Diogo quem empunhou a arma ou de que não sabia que ela seria utilizada.

Afinal, tendo ele adentrado no local do crime na companhia do comparsa armado e que fez uso do revólver para render os ofendidos, não paira dúvida de que Diogo agiu

com consciência e vontade de cometer roubo mediante emprego de arma de fogo. Do contrário, ao notar que o corréu fazia uso de um revólver, se não concordasse com isso, simplesmente deveria ter deixado a casa das vítimas sem tencionar a subtração de algo.

Porém, como disse a vítima Francisco, enquanto ela era subjugada mediante apontamento de uma arma de fogo contra sua cabeça, Diogo vasculhou o interior do imóvel à procura de outros itens a serem roubados, e só não subtraiu mais nada porque, em seguida, um barulho vindo da rua alertou os assaltantes.

Tampouco merece guarida a tese de que o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal teria sido revogado.

Não houve a revogação da causa de aumento de pena para a conduta de quem comete roubo mediante emprego de arma de fogo.

A Lei n. 13.654/2018, ao mesmo tempo em que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, incluiu no sobredito dispositivo legal o § 2º-A, inciso I, com a seguinte redação:

"§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;"

Como se observa, a conduta em questão nunca deixou de merecer resposta mais rigorosa por parte do legislador.

No caso, em se tratando de fato praticado antes da vigência da alteração legislativa, que importou em recrudesimento da pena para o agente que rouba com emprego de arma de fogo, deve-se aplicar a lei vigente na data do crime, de modo que o aumento de pena deve se basear no revogado inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, que prevê fração de majoração inferior ao da nova lei (dois terços). De resto, não há que se falar em irrelevância penal do fato ou em aplicação do princípio da insignificância.

Não se pode considerar irrelevante fato em que três agentes cometem roubo cuja prática envolve o apontamento de arma contra a cabeça da vítima.

Aliás, a jurisprudência tem entendido que o princípio da insignificância é incompatível com o delito de roubo.

Confira-se o seguinte julgado:

"Impossível, ainda, acolher a tese defensiva que busca o reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que a bagatela penal não é consagrada pelo ordenamento jurídico. O crime de bagatela é construção doutrinária, não referendada por esta Câmara. Ainda que fosse, a pretexto de esclarecimento, a expressividade econômica do objeto material do delito, por não ser um critério seguro, não deve servir de parâmetro para o seu reconhecimento. Desse modo, bens jurídicos penais, ainda que possuam valores irrisórios, também devem ser tutelados pelo Direito Penal, não havendo que se falar em atipicidade, ainda mais em se tratando de roubo, delito complexo em que há ofensa a bens jurídicos diversos, no caso, o patrimônio e a integridade da pessoa." (TJSP, Apelação n. 0048519-13.2011.8.26.0554, rel. Rachid Vaz de Almeida, j. 05/02/2015).

Ademais, a subtração recaiu sobre a quantia de R\$ 500,00, que é superior a 10% do salário mínimo da data do fato.

Tal percentual tem sido utilizado como baliza para definir valor insignificante, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

"Quanto à aplicação do princípio bagatelar esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos." (AgRg no AREsp n. 849458/SP, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2016/0031323-5, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, 15/03/2016).

Por último, não há que se falar em participação de menor importância.

A conduta do acusado Diogo não se resumiu a mera participação, tendo sido ele, na verdade, autor e executor material do delito.

Destarte, a condenação na forma proposta na denúncia é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu Diogo ostenta maus antecedentes (fls. 250 e 254 - artigo 157, § 2º, II,

Código Penal; e fls. 512 - artigo 157, § 2o, incisos I e II, c c artigo 14, II, Código Penal).

Vale lembrar que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado em ocasiões posteriores à prática do novo crime, se não caracterizam reincidência, prestam-se a configurar maus antecedentes.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO ILÍCITO EM EXAME. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - As condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal em destaque, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem, à toda evidência, para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. (STJ, AgRg no REsp 1752146 / MG, Agravo Regimental no Recurso Especial 2018/0162516-5, Relator Ministro Félix Fischer, 5a Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Diante disso, eleva-se a pena base na proporção de um sexto, resultando em quatro anos e oito meses de reclusão, mais onze dias-multa.

O réu Diogo é, ainda, reincidente (fls. 513/515 - artigo 157, § 2o, I, II e V, Código Penal).

Contudo, ele confessou a prática do delito na fase judicial.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência." (HC n. 288.910/SP, 6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

Destarte, na segunda fase de aplicação da pena, compensa-se integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo-se a reprimenda no mesmo patamar anterior.

Presentes as causas de aumento dos incisos I e II do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e sem perder de vista o enunciado da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, eleva-se a pena na proporção de um terço, resultando em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais quatorze dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Diante dos maus antecedentes e da reincidência específica, bem como das circunstâncias do crime (cometido por três agentes mediante emprego de arma de fogo), o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

É inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, seja porque se trata de crime cometido mediante grave ameaça, seja porque o montante da pena não a permite.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Diogo Antônio da Silva como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, a cumprir seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quatorze dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

O réu foi preso preventivamente no curso do processo e permaneceu encarcerado durante a instrução. Agora, condenado a cumprir pena longa, em regime inicial fechado, com maior dose de razão há de permanecer encarcerado provisoriamente, pois há o risco de que, se solto, busque se subtrair à aplicação da lei penal, mormente se se considerar que permaneceu foragido durante razoável período de tempo. Tudo sem contar, ainda, na probabilidade de reiteração de prática criminosa, tendo em vista os antecedentes. Expeça-se, pois, ofício de recomendação.

P.R.I.

Bauru, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA